

1500610-86.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500610-86.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500610-86.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145918/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 25254460 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2145918 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO VIEIRA DE CASTRO JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Emerson Diego da Silva e Ricardo Vieira de Castro Júnior, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.

Segundo a denúncia, os acusados, no dia 29 de maio de 2022, às 23h30min, na Rua Professor José Torres Brito, número 7-63, no bairro Vila Seabra, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraíram, para si, mediante concurso de pessoas, 01 hidrômetro da vítima, representada por Jair Aparecido Baldenebro.

Ainda, segundo a inicial os acusados, no dia 29 de maio de 2022, na Rua Américo Bertoni, quadra 4, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraíram para eles,

mediante concurso de pessoas, 01 hidrômetro de um terreno baldio. Boletim de ocorrência (fls. 13/17), autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 20/22), auto de reconhecimento (fls. 23), auto de avaliação (fls. 24), relatório policial final (fls. 142/144).

Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 120/124), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 148/149 foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados.

Os réus foram citados (fls. 161 e 163), tendo ofertado respostas à acusação (fls. 167/169).

Na decisão de fls. 189/190, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 208/210 foram ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação/defesa e interrogados os réus.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 243/247 pugnando, em suma, pelo parcial acolhimento da pretensão punitiva, absolvendo-se os acusados apenas no tocante ao delito ocorrido no terreno baldio, condenando-os pela infração penal perpetrada na igreja, bem como a constatação dos maus antecedentes e da culpabilidade acentuada, a valoração das reincidências e da agravante do “estado pandêmico”, e da majorante do repouso noturno, fixando-se os regimes iniciais fechado.

Já a Defensoria Pública, às fls. 254/274, em resumo, pleiteou pela absolvição por insignificância penal, ou o afastamento da majorante do repouso noturno, o reconhecimento da tentativa na máxima extensão, a fixação do regime inicial mais brando, a constatação da “detração processual”.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17), autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 20/22), auto de reconhecimento (fls. 23), auto de avaliação (fls. 24), relatório policial final (fls. 142/144).

As autorias, de outra banda, também induzem a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima José Aparecido Baldenebro, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que foi avisado acerca do furto do hidrômetro. Afirmou que foi até a delegacia e reconheceu a res furtiva como pertencente à igreja 'Congregação Cristã'. Informou que não soube quem foram os autores do crime.

Os policiais militares Diego Luiz de Souza Bono e Wendell Mak de Mendonça e Silva, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que estavam em patrulhamento, quando foram avisados de que duas pessoas tinham subtraído o hidrômetro de uma igreja. Afirmaram que, em patrulhamento, encontraram os acusados, pessoas com as mesmas características descritas, sendo que cada um deles trazia consigo um hidrômetro. Informaram que eles confessaram a prática do furto, dizendo que um dos hidrômetros foi furtado da igreja, enquanto o outro foi subtraído de um terreno baldio. Esclareceram que a vítima Jair reconheceu a hidrômetro da igreja, entretanto, não foi possível encontrar o ofendido do hidrômetro do terreno baldio. Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: “Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha”.

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Emerson Diego da Silva, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou os fatos. Disse que 'estavam com vontade de consumir droga e resolveram subtrair o hidrômetro'. Afirmou que o segundo hidrômetro não foi subtraído do terreno, mas sim de sua casa.

O acusado Ricardo Vieira de Castro Júnior, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em síntese, confessou a prática delitiva. Disse que apenas o hidrômetro da igreja foi subtraído, sendo que o segundo objeto citado era da casa de Emerson, e, portanto, não foi subtraído.

Da prova colhida, forçoso convir que os acusados cometeram apenas o delito em detrimento da igreja.

Com efeito, os réus confessaram o delito.

O hidrômetro foi reconhecido pelo representante da vítima.

Depois, os acusados foram surpreendidos pelos policiais ainda em posse da res furtiva.

De outro lado, incabível a aplicação do princípio da insignificância.

Com efeito, ambos os acusados possuem passado criminal (fls. 73/106 e 211/236).

Em acréscimo, cometeram o delito em comparsaria, qualificação que impede a benesse. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.

2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

3. Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao

examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).

4. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes.

5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.

6. Ademais, a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

7. Na hipótese em análise, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, mesmo o bem subtraído (1 fogareiro de duas bocas, marca Ramos, avaliado em R\$ 70,00) não superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R\$ 954,00 em 2018), o acusado é multirreincidente, além do delito ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e não configura a mínima ofensividade do comportamento do acusado.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 2181925 / PR, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/11/2022)

Sob outro vértice, o delito restou consumado.

Os policiais abordaram os acusados com os objetos enquanto caminhavam, ou seja, quando os bens já não mais estavam na esfera de disponibilidade do proprietário. É a inteligência do item 1, da edição nº 47 da Ferramenta "Jurisprudência em Teses", do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: "1) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)" No mais, quanto ao delito supostamente cometido em detrimento do "terreno baldio" há dúvidas.

Eventual vítima não foi localizada.

Ademais, o acusado Emerson citou que um dos hidrômetros era de sua casa, no que foi corroborado pelo corréu.

De se citar, por oportuno, que não é comum que em um terreno baldio exista hidrômetro.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal, por uma vez (em detrimento da igreja).

Sob outro aspecto, devem os réus permanecerem custodiados.

O acusado Emerson (fls. 73/88 e 100/106), possui cinco feitos aptos a caracterizar reincidências: 25151/2009, 1503/2011, 10290-2009, 0002211-39.2013 e 0021260-66.2013.

O acusado Ricardo é portador, de outro lado, de dois feitos caracterizadores de reincidências (fls. 89/99): 0018655-89.2009 e 0002530-36.2009.

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO

E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Por fim, inaplicável o instituto da detração penal.

Primeiro, por que o pressuposto de validade processual repousa perante o Douto Juízo das Execuções.

Assim:

"APELAÇÃO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. APRECIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstrado pelo robusto conjunto probatório que o apelante portava, sem autorização legal ou regulamentar, a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, incensurável se mostra a solução condenatória proferida. Ademais, nenhum reparo merece a sentença no que tange à aplicação da detração penal. O legislador inseriu o § 2º no artigo 387 do CPP, por meio da Lei nº 12.736/12, dispondo que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Cabe ao Juízo da Execução Penal apreciar se o condenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo ele, portanto, o competente para a apreciação do referido pleito, consoante o preceituado no artigo 112 da Lei nº 7.210/84. DESPROVIMENTO DO RECURSO".

(TJ-RJ - APL: 040028532201481900001 RJ 0400285-32.2014.8.19.00001, Relator: DES. ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 13/10/2015, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2015 17:05)

Em segundo plano, mesmo que assim não o fosse, não houve a possibilidade de contraditório, ferindo de morte o devido processo legal em sua acepção material. Sob outra vértice, impossível a aferição do mérito carcerário, requisito subjetivo para a aplicação da benesse.

Com efeito, a detração penal é matéria de execução, nos termos do art. 66, III, "c" da LEP.

Outrossim, em que pese tal "detração" relacionar-se a regime de imposição, não é menos verdade que até a fixação dele é relacionada à pena lançada.

Eis a menção do art. 59, III, do Código Penal, verdadeiro "vetor" da culpabilidade: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

Ou seja, o próprio regime de pena encontra pressuposto de validade na individualização da pena.

Assim, para além da questão única da competência, a inobservância de requisitos objetivos e subjetivos mínimos, macularia a própria isonomia, e, ainda, a reprovação ao delito cometido.

Passo à fixação da pena.

Réu Emerson Diego da Silva

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A culpabilidade é acentuada.

Com efeito, a conduta foi praticada quando o acusado cumpria pena em regime aberto. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP.

PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO

MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.

312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja tão elevada a ponto de, isoladamente, demonstrar a acentuada reprovabilidade da suposta conduta ilícita, o Juízo singular evidenciou o risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente, além de registrar passagens pretéritas por crimes de mesma natureza, cumpria pena em regime aberto, decorrente de condenação por tráfico de drogas, no momento da prisão em flagrante objeto desta impetração, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar.

3. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

5. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, ante a ausência de menção a elementos concretos dos autos que evidenciem não ser recomendável o convívio da acusada com a criança, bem como o fato de o delito imputado à paciente - tráfico de drogas - não haver sido cometido com violência ou grave ameaça, tampouco contra seu filho.

6. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e substituir a prisão preventiva da acusada pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, bem como pelas medidas cautelares apontadas no voto. (STJ, 6ª Turma, HC 591754 / SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 03/11/2020, g.n.)

Por fim, consequências e circunstâncias não transbordam as barreiras do tipo. Deste modo, a pena-base deve ser exasperada em 1/6, perfazendo, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na mesma fase, como dito, são cinco reincidências.

Uma delas é compensada com a confissão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira.

III - No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(STJ, 5ª Turma, EDcl no HC 460831 / SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Portanto, a pena é agravada em 2/3, perfazendo 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento 18 (dezoito) dias-multa.

Na fase final, a majorante do "repouso noturno" deve ser aplicada.

Ocorre que em razão da menor vigilância a citada causa de aumento é incidente, ainda que estabelecimentos comerciais.

Nesse sentido:

Ementa: Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida. Repouso noturno – Crime praticado em período de menor vigilância – Majorante pode ser reconhecida mesmo em área comercial – Pleito de afastamento desacolhido. Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Duas qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável – Recurso provido em parte para reduzir o acréscimo aplicado. Continuidade delitiva com furto apurado em processo distinto – Feitos que não foram reunidos na origem e geraram apelações distribuídas em Câmaras diferentes – Aplicação do artigo 71 do Código Penal deve ser realizada no Juízo das Execuções – Recurso provido em parte para afastar o acréscimo do crime continuado

(STJ, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000197-85.2018.8.26.0660, relator Des. Klaus Marouelli Arroyo, julgado em 19/08/2022)

É dizer, em casos de delitos qualificados, já mais graves, jamais a reprimenda seria “justa”, pois a majorante jamais seria aplicada.

Ou seja, haveria patente desproporcionalidade, na acepção da proibição de proteção ineficiente.

Além disso, eis a redação do art. 155, §1º do Código Penal: § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Da simples leitura, possível concluir que não há limitação ao delito simples.

Tanto é assim, que o §4º assim preconiza: § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

Na mesma linha, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, de 04/11/1940, item 56: É prevista como agravante especial do furto a circunstância de ter sido o crime praticado “durante o período do sossego noturno”.

Portanto, a aplicação visa homenagear a individualização da pena, verdadeiro direito fundamental.

Por isso, a pena é aumentada em 1/3, atingindo, em definitivo, 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Réu Ricardo Vieira de Castro Júnior

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

O acusado experimentava o livramento condicional, quando praticou o delito.

Por isso, nos mesmos moldes do corrêu, a culpabilidade é acentuada.

Por fim, consequências e circunstâncias não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena-base deve ser exasperada em 1/6, perfazendo, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, inaplicável a agravante do “estado pandêmico”, tal qual mencionado.

Ainda na segunda fase, o acusado possui 2 feitos caracterizadores de reincidências.

Um deles, como argumentado, compensa-se com a atenuante da confissão.

Por isso, a pena é agravada em 1/6 resultando em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) diárias.

Na final, demonstrada a majorante do “repouso noturno”, pelo que, a pena é aumentada em 1/3, totalizando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime é o inicial fechado para ambos os acusados.

Com efeito, as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Depois, os acusados são portadores de reincidências, fator que escapa da aplicação da Súmula nº 269 do STJ.

No ponto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA JUSTIFICADOS.



1. "Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia. A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação" (HC n. 352.237/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016).

2. "É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 476.217/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021).

3. E, quanto à substituição, "presente circunstância judicial desfavorável, a qual justificou o estabelecimento da pena-base acima do piso, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos não é recomendável à espécie, ainda que o montante da pena atenda ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP" (HC n. 361.623/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 745644 / SC, relator Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 27/09/2022)

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos réus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA na ação penal e, desta feita:

ABSOLVO os réus EMERSON DIEGO DA SILVA E RICARDO VIEIRA DE CASTRO JÚNIOR, outrora responsabilizados pelo delito previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal (furto em terreno baldio), nos termos do art. 386, VII do CPP;

CONDENO o réu EMERSON DIEGO DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal;

CONDENO o réu RICARDO VIEIRA DE CASTRO JÚNIOR, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal.

Nego aos acusados o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagarem a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA